

主尋問後に証人が所在不明になるなどの事情により反対尋問を経していない証人の証言の証拠能力に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 伝聞証拠とは、反対尋問を経していない供述証拠であることを強調すると、反対尋問を受けておらず、伝聞証拠に当たることになるから、前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
- イ. 「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない」という刑事訴訟法第320条第1項の文言を言葉どおりに解釈すると、前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
- ウ. 裁判官が証人の証言態度等を直接観察していることを重視すると、前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付く。
- エ. 証人は、宣誓をしており、偽証罪による制裁という威嚇がある下での供述であることを重視すると、前記証言の証拠能力を肯定する見解に結び付く。
- オ. 前記証言が伝聞証拠に当たらないとの見解に立っても、反対尋問が実施できなくなった事情について証人申請をした当事者の責めに帰すべき理由がある場合には、手続的正義に反し、証拠能力が否定されると考えることも可能である。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 正しい

伝聞証拠かどうかの判断について、反対尋問を経していない供述証拠かどうかを重視する見解は、伝聞証拠かどうかを反対尋問を経ているかどうかで判断する。そうすると、本問における主尋問後に証人が所在不明になるなどの事情により反対尋問を経していない証人の証言（以下「前記証言」という。）は、反対尋問を経していない以上、伝聞証拠に当たり原則として証拠能力が否定されることになる（伝聞法則、320条1項参照）。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

伝聞証拠かどうかの判断について、320条1項の文言を言葉どおりに解釈すると、伝聞証拠かどうかは、反対尋問を経たかどうかではなく、「公判期日における供述」かどうかで判断される。そうすると、前記証言は反対尋問を経していないものの、主尋問には答えているのであるから公判期日における供述といえ、伝聞証拠には当たらない。よって、証拠能力が肯定されることになる。したがって、本記述は、文言を言葉どおりに解釈すると、前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付くとしている点で、誤っている。

ウ 誤っている

供述証拠について、供述内容の真実性を担保する方法として反対尋問は重要な手段ではあるが、それだけが唯一のものではないと考えると、供述内容の真実性は相手方当事者による反対尋問の他に、①宣誓と偽証罪の制裁、②事実認定者による供述態度の観察を通して担保されるといえる。そうすると、前記証言が反対尋問を経していないものであっても、裁判官が証人の証言態度等を直接観察していることを重視すると、前記証言の証拠能力を肯定することができる。したがって、本記述は、前記証言の証拠能力を否定する見解に結び付くとしている点で、誤っている。

エ 正しい

供述証拠について、供述内容の真実性を担保する方法として反対尋問は重要な手段ではあるが、それだけが唯一のものではないと考えると、供述内容の真実性は相手方当事者による反対尋問の他に、①宣誓と偽証罪の制裁、②事実認定者による供述態度の観察を通して担保されるといえる。そうすると、前記証言が反対尋問を経していないものであっても、証人は宣誓しており、偽証罪による制裁という威嚇がある下での供述であることを重視すると、前記証言の証拠能力を肯定することができる。したがって、本記述は正しい。

オ 正しい

前記証言が伝聞証拠に当たらないとの見解に立っても、証人が主尋問に出頭しない又は出頭しても反対尋問に答えないときは、その相手方は憲法で保障された証人審問権（憲法37条2項）を奪われることになる点を重視して、反対尋問が実施できなくなった事情について証人申請をした当事者の責めに帰すべき理由がある場合には、手続的正義に反し、証拠能力が否定されることが考えられることも可能である。したがって、本記述は正しい。

以上により、誤っている記述はイとウであり、したがって、正解は肢3となる。